

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

13673/2557

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นางสาวบุญยานุชหรือหทัยทัต สีเขียว

กับพวก

โจทก์ร่วม

นายกิตติพงศ์หรือนุกหรือนุก สีนภูเขียว

กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 276, มาตรา 281

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

ความผิดฐานร่วมกันกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงนั้นจะต้องมีลักษณะของการสมคบกันมาแต่ต้น และขณะเกิดเหตุได้ผลัดเปลี่ยนกันข่มขืนกระทำชำเราหญิงด้วย แต่ทางนำสืบของโจทก์และโจทก์ร่วมมิได้นำสืบให้เห็นว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันสมคบคิดมาแต่ต้นกันอย่างไร และไม่ปรากฏว่าก่อนจำเลยที่ 1 จะข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 1 จำเลยทั้งสามได้ตกลงให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 รออยู่นอกห้องนอนเพื่อให้จำเลยที่ 2 รอที่จะข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 1 เป็นคนถัดไป ประกอบกับจำเลยที่ 2 ได้พูดขอมิเพศสัมพันธ์กับโจทก์ร่วมที่ 1 ในลักษณะขอความยินยอมจากโจทก์ร่วมที่ 1 ก่อน เมื่อโจทก์ร่วมที่ 1 ไม่ยินยอมจำเลยที่ 2 จึงใช้กำลังข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 1 แต่ไม่สำเร็จ หากจำเลยที่ 2 มีเจตนาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 1 มาแต่ต้น จำเลยที่ 2 คงจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง

เพื่อข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 1 ในทันทีที่พบ คงไม่ร้องขอเพื่อพูดขอร่วมเพศกับโจทก์ร่วมที่ 1 ด้วยความสมัครใจของโจทก์ร่วมที่ 1 ก่อน พฤติการณ์แห่งคดียังไม่อาจรับฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุจำเลยทั้งสามร่วมกันผลัดเปลี่ยนข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 1 จึงไม่มีความผิดฐานร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงตาม ป.อ. มาตรา 276 วรรคสาม แต่เป็นความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราตาม ป.อ. มาตรา 276 วรรคแรก ฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเรา และฐานช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกผู้อื่นกระทำความผิดดังกล่าวตามลำดับ ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้ตาม ป.อ. มาตรา 281 เมื่อจำเลยทั้งสามอุทธรณ์โดยมีบันทึกการชดเชยเยียวยาให้แก่โจทก์ร่วมทั้งสองแนบท้ายอุทธรณ์ มีข้อความว่า โจทก์ร่วมทั้งสองซึ่งเป็นผู้เสียหายไม่ประสงค์ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสามอีกต่อไป จึงถือได้ว่าการถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกันแล้ว ย่อมมีผลทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ระงับไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 276, 318

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นางสาวบุญยหนูหรือหทัยทัต ผู้เสียหายที่ 1 และนายสามารถผู้เสียหายที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสาม, 318 วรรคสาม ประกอบมาตรา 83 จำเลยที่ 3 มีความ

ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสาม, 318 วรรคสาม ประกอบ มาตรา 86, 83 การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 กระทำความผิดจำเลยทั้งสามอายุกว่าสิบห้าปี แต่ไม่เกินสิบแปดปี ลดมาตราส่วนโทษ ให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฐานร่วมกัน ข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง จำคุกคนละ 7 ปี 6 เดือน ฐาน ร่วมกันพราກผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ไม่เกินสิบแปดปี ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ ปกครองหรือดูแลเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วย จำคุกคนละ 1 ปี 6 เดือน รวมจำคุกคนละ 8 ปี 12 เดือน ส่วนจำเลยที่ 3 ฐานเป็นผู้สนับสนุนการข่มขืน กระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง จำคุก 5 ปี ฐานร่วมกันพราກผู้เยาว์อายุ กว่าสิบห้าปี แต่ไม่เกินสิบแปดปี ไปเสียจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองเพื่อการ อนาจาร โดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วย จำคุก 1 ปี 6 เดือน รวมจำคุก 6 ปี 6 เดือน อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 142 (1) เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นการส่งตัว จำเลยทั้งสามไปฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกและอบรมกรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีกำหนดคนละ 3 ปี จำเลยที่ 3 มีกำหนด 2 ปี

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318 วรรคสาม ลดมาตราส่วนโทษเรื่อง อายุแล้ว คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน และปรับ 10,000 บาท ไม่เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่ง ฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 142 (1) แต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี นับจากได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 พัง โดยให้จำเลยที่ 1 ไป

รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติปีละ 3 ครั้ง ตามที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรกำหนด กับให้จำเลยที่ 1 ละเว้นการประพฤติได้อันอาจนำไปสู่การกระทำความผิดทำนองนี้อีก และให้จำเลยที่ 1 กระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลยที่ 1 เห็นสมควรเป็นเวลา 30 ชั่วโมง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากไม่ชำระค่าปรับให้ส่งตัวไปฝึกและอบรมในกรุงเทพมหานคร มีกำหนด 50 วัน ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ มาตรา 145 และหากจำเลยที่ 1 ถูกควบคุมให้หักระยะเวลาที่ถูกควบคุมออกจากค่าปรับวันละ 200 บาท จำหน่ายคดีจำเลยทั้งสามในความผิดฐานร่วมกันข่มขืนกระทำชำเรา อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงตามฟ้องยกฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในความผิดฐานร่วมกันพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวตรวจวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันรับฟังเป็นยุติว่า ขณะเกิดเหตุโจทก์ร่วมที่ 1 อายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี อยู่ในความปกครองดูแลของโจทก์ร่วมที่ 2 ซึ่งเป็นบิดา วันเกิดเหตุวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลาประมาณ 16.30 นาฬิกา ขณะโจทก์ร่วมที่ 1 ยืนรอนางสาวฟองแก้ว เพื่อนโรงเรียนเดียวกันที่บริเวณป้ายหยุดรถรับส่งผู้โดยสารประจำทาง ห่างจากแฟลตที่พักทหารยานเกาะ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประมาณ 100 เมตร จำเลยที่ 1 ชวนโจทก์ร่วมที่ 1 ไปห้องเกิดเหตุซึ่งเป็นห้องที่จำเลยที่ 3 พักอาศัยอยู่ในแฟลตดังกล่าว เมื่อไปถึงบริเวณหน้าห้องที่เกิดเหตุโจทก์ร่วมที่ 1 ไม่ยอมเข้าไปในห้องเกิดเหตุ จำเลยที่ 1 ดึงแขนโจทก์ร่วมที่ 1 เข้าไปในห้องนอน ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของห้องเกิดเหตุ ขณะนั้นจำเลยที่ 2 และที่ 3 อยู่บริเวณห้องโถงของห้องเกิดเหตุ จากนั้นจำเลยที่ 1 ผลักโจทก์ร่วมที่ 1 ให้นอนลงบนที่นอน

แล้วขึ้นคร่อมกดทับตัวและใช้มือกดหัวไหล่ของโจทก์ร่วมที่ 1 ไว้จนทำให้โจทก์ร่วมที่ 1 อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขยับขึ้นได้ จำเลยที่ 1 ข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 1 จนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้ง คดีเป็นอันยุติสำหรับจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 กระทำผิดฐานพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ข้อแรกมีว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 1 อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่าการที่จำเลยทั้งสามจะมีความผิดในฐานตัวการร่วมดังกล่าวจำเลยทั้งสามต้องสมคบกันมาแต่ต้น และขณะเกิดเหตุก็ได้ผลัดเปลี่ยนกันข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 1 ด้วย แต่ทางพิจารณาโจทก์และ โจทก์ร่วมทั้งสองมิได้นำสืบให้ เห็นว่า จำเลยทั้งสามร่วมสมคบคิดมาแต่ต้นกันอย่างไร และไม่ปรากฏว่าก่อนจำเลยที่ 1 จะข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 1 นั้น จำเลยทั้งสามได้ตกลงให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 รออยู่นอกห้องนอนเพื่อให้จำเลยที่ 2 รอที่จะเข้าข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 1 เป็นคนต่อไป ประกอบกับจำเลยที่ 2 ได้พูดขอร่วมเพศกับโจทก์ร่วมที่ 1 ในทำนองขอความยินยอมจากโจทก์ร่วมที่ 1 ก่อน เมื่อโจทก์ร่วมที่ 1 ไม่ยินยอมจำเลยที่ 2 จึงใช้กำลังข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 1 แต่ไม่สำเร็จ หากจำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 1 มีเจตนาที่จะร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 1 มาแต่ต้น จำเลยที่ 2 คงจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 1 ในทันทีที่เข้าไปพบโจทก์ร่วมที่ 1 ในห้องนอน จำเลยที่ 2 คงไม่ต้องร้องรอเพื่อพูดขอร่วมเพศกับโจทก์ร่วมที่ 1 ด้วยความสมัครใจของโจทก์ร่วมที่ 1 ก่อนเป็นแน่ พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดียังไม่อาจรับฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุจำเลยทั้งสามมีเจตนาร่วมกันผลัดเปลี่ยนข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 1 มาแต่ต้น ถือว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่างมีเจตนาของตนเองไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน จำเลยทั้งสามจึงไม่มีความผิดฐานร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมที่ 1 อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงตามฟ้อง แต่จำเลยทั้งสามมีความผิด

ฐานข่มขืนกระทำชำเรากับฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเราและฐานช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกผู้อื่นกระทำความผิดดังกล่าวตามลำดับ ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 281 เมื่อจำเลยทั้งสามยื่นอุทธรณ์โดยมีบันทึกการชดเชยเยียวยาให้แก่โจทก์ร่วมทั้งสองแนบท้ายอุทธรณ์ ซึ่งบันทึกดังกล่าวปรากฏข้อความว่า โจทก์ร่วมทั้งสองซึ่งเป็นผู้เสียหายไม่ประสงค์ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสามอีกต่อไป จึงถือได้ว่าการถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกันแล้ว ย่อมมีผลทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์เฉพาะข้อหาดังกล่าวระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา มาตรา 39 (2) ที่ศาลอุทธรณ์จำหน่ายคดีจำเลยทั้งสามในความผิดฐานร่วมกันข่มขืนกระทำชำเรา อันมีลักษณะเป็นการโทรมหนี้ยินยอมแล้วฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(บุญไชย ธนาพันธ์สิน-พฤษภา พนมยันตร์-จรูญ ชีวิทโสภณ)

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง - นายอาวุธ อักษรพันธ์

ศาลอุทธรณ์ - นายจักรกฤษณ์ เจนเชษฐา

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก เยาวชนและครอบครัว

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ847/2555

ต้น หมายเหตุ